

1500428-60.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186892/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 26059288 -

DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2186892 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS MAXIMIANO PENHA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500428-60.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500428-60.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186892/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 26059288 -

DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2186892 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIS MAXIMIANO PENHA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de ANDRÉ LUÍS MAXIMIANO PENHA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, eis que no dia 11 de junho de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Professora Silvia Martins Silveira de Silos, nº 65, e na Alameda José Franco Meirelles, nº 97, Domingo de Sylos, nesta cidade e comarca, vendia e guardava 152 (cento e cinquenta e dois) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando cerca de 197,30 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 41/43 veio acompanhada do Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de páginas 01/92.

Prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme termo de audiência de custódia de págs. 48/57.

O réu foi notificado (págs. 86) e apresentou defesa preliminar (págs. 106/110), sustentando que a droga apreendida não tem condão de indicar a propriedade como sendo do acusado. Neste sentido, não existem provas suficientes que possam comprovar a autoria delitiva. Requer a absolvição sumária do réu.

A denúncia foi recebida aos 19 de agosto de 2022, onde designou-se data para audiência de instrução, debates e julgamento (pág. 111/113).

Durante a solenidade de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em debates, o Ministério Público requer a procedência da ação penal. Autoria e materialidade comprovadas, segundo sustentado na gravação. Refere-se ao depoimento dos policiais que viram o réu em atividade típica de traficância e o réu teria indicado a outra casa – do seu pai – como depósito de drogas. Ainda que apenas a droga encontrada apenas na casa do genitor seja considerada isso não afasta a tipicidade da conduta. O réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, porém confesso. Na terceira fase pugna pelo afastamento do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, requerendo a fixação de regime semiaberto.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se no sentido de que o conjunto probatório comprova a prática delitiva. Pugna pela observância da confissão como circunstância atenuante, o que é direito subjetivo do réu.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 25), auto de constatação preliminar (págs. 27) e pelos laudos periciais de páginas 88/90. Foram apreendidas 44,4 gramas de cocaína, conforme massa líquida do laudo pericial.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Welther Vaz Martins informa que aportou uma denúncia na delegacia de Casa Branca, 10 a 15 dias antes, informando que o réu estava traficando. Devido a demanda, vieram verificar pouco depois e, de fato, constataram que o réu traficava defronte à residência. Ele chegava a colocar uma cadeira na frente da casa e pessoas se aproximavam. Viram 2 transações semelhantes e resolveram abordar o réu que permaneceu calado, mas disse que havia mais droga. Havia mais de 90 porções de droga dentro do imóvel e na casa do genitor dele mais 50 porções de drogas. O genitor morava ali próximo. O réu foi colaborativo e indicou o local senão não encontrariam a casa do pai. Ele disse que era egresso do sistema penitenciário e com dificuldade de conseguir emprego resolveu traficar novamente. Portanto, a justificativa era por dificuldades financeiras. Havia salvo engano R\$ 20,00 ou R\$ 30,00 da negociação que presenciaram. Não se lembra se as notas estavam fracionadas. O outro indivíduo que foragiu não foi identificado, mas era típico usuário. Ele foi comprar. Estavam em poucos policiais, tentaram abordar, mas ele conhecia o relevo melhor e fugiu. Ele dispensou uma porção. A casa onde André estava ele falou que ficava ali. O réu entrava na casa e saía. A cadeira ficava na frente e quando alguém chegava o réu entrava na casa e saía rapidamente. A droga estava num rack, dentro de um boné.

Artibano José Cruz relata que uns dias antes receberam denúncia na delegacia especializada e resolveram averiguar. Ficaram observando por alguns instantes, chegou um usuário e numa movimentação rápida, não conseguiram abordar. Veio outro usuário e fez a mesma movimentação de compra e então tentaram a abordagem, mas o rapaz evadiu-se. O réu então foi abordado defronte à casa e disse que tinha saído da cadeia e realmente estava traficando porque estava passando dificuldades. Ele indicou onde estava a droga dentro da casa – 99 porções num rack. Debaixo do guarda-roupas da casa do pai dele também encontraram mais porções de drogas. Foi o réu quem indicou o outro endereço. O réu colaborou e levou a equipe até a residência do genitor. Não fez contato com o genitor do réu. A primeira casa, ficaram em dúvida se era dele ou não ou talvez de algum comparsa. O réu disse que estava passando por dificuldades.

André Luís Maximiano Penha, em oportunidade de autodefesa disse que foi preso por tráfico numa primeira vez e ficou em Itirapina de 3 a 4 meses preso pelo mesmo caso. Uso abusivo de drogas. Conseguiu ganhar o "BO". Tem 32 anos atualmente. Trabalha na roça e também como servente de pedreiro quando tem serviço. Mora com seu pai. A residência do seu pai é onde mora de verdade. Foi internado em 2019 por causa de drogas. Fazia 2 anos que estava em liberdade. Entrou em dezembro de 2019 e saiu no começo de 2020. Tinha acabado de sair da clínica. Na casa onde foram encontrados os noventa e poucas porções não é sua. Eles arrombaram a casa. Falou para eles que era usuário de drogas e o que vendia estava na sua casa, que era a casa do seu pai, e que vendia para manter seu vício. Na casa que não lhe pertence não entrou nela em momento algum. Os policiais diziam que tinham que tirar um cara de lá, mas não sabe de quem eles estavam falando. Em momento algum entrou na casa. Estava sentando para fora, na calçada. Quer dizer que infelizmente caiu nesse erro por causa do vício e é usuário crônico de cocaína. Seu pai não sabia que havia droga na casa e se ele souber "Nossa Senhora da Aparecida" "dá um infarto nele". Não estava vendendo na frente da casa quando a polícia chegou. Estava ali esperando para comprar maconha com os R\$ 20,00 que estavam no seu bolso. A atividade de

tráfico narrada pelos policiais não viu nada. A porta estava trancada e não tinha ninguém e nisso foi abordado. Confirma que não entrou na casa, em momento algum. Indicou espontaneamente onde era a casa do seu pai. A droga que estava na casa do seu pai era cocaína.

2-) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL:

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não pode o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório,

portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

E, no presente caso, a lisura do procedimento policial veio mais uma vez cancelada pela confissão do réu, assim considerada a "rainha das provas".

Destarte, não há campo para desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco para absolvição do réu, pois ambos os policiais empenhados na diligência são experientes e sabem discernir atos de entrega de drogas ao consumo de terceiros, o que aliado à confissão do réu, impede solução diversa senão a total procedência da ação penal.

No que tange à alegada drogadição, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

O alegado estado de necessidade não conta com qualquer respaldo probatório e não está presente o requisito da inevitabilidade.

O estado de necessidade para se configurar exige a existência de um perigo atual, não provocado pelo agente e que não possa ser evitado por outros meios, além da proporcionalidade dos bens em confronto.

Fica afastada a possibilidade de estado de necessidade exculpante, seja como causa excludente da ilicitude, seja como causa de diminuição de pena (art. 24, § 2º, do CP) ou mesmo como atenuante genérica prevista no art. 65, III, "a", do CP

Presente a tipicidade delitiva e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 41/43 para CONDENAR ANDRÉ LUÍS MAXIMIANO PENHA pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe a pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Iniciando pelas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, tem-se que o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas (neste caso não é suficiente para gerar acréscimo na pena, pois a apreensão foi de cerca de 44,4 gramas de cocaína, conforme massa líquida verificada em laudo pericial de págs. 88/89.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analizadas tais diretrizes conclui-se que nenhum acréscimo de pena afigura-se necessário, pois a quantidade é considerada pequena e havia apenas um tipo de droga com o réu. A substância apreendida - cocaína - é comum, de modo que também pela natureza não se legitima nenhum recrudesimento na sanção.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu ostenta maus antecedentes, pois definitivamente condenado nos autos da ação penal Foro de Itapira - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumário: 0001631-80.2016.8.26.0272 - transitado em julgado aos 08.02.2022.

Como sabido, perfeitamente possível que eventos anteriores com trânsito em julgado posterior sejam considerados para fins de maus antecedentes, sendo que a condenação supra decorre de fato ocorrido aos 27.04.2016.

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CRIME ANTERIOR AO APURADO NOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise, mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da pena-base pela valoração negativa dos antecedentes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Habeas Corpus nº 502.995/MS (2019/0098424-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 15.08.2019, DJe 23.08.2019).

Na primeira fase, diante dos maus antecedentes, a pena fica estabelecida em 1/6 acima do mínimo legal e passa a ser de 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa, na

proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, o réu confessou e deve ser beneficiado, na forma da súmula 545 do E. STJ, o que reconduz a pena ao mínimo legal de 5(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se pode considerar a condenação por prática da infração penal sui generis prevista no art. 28 da Lei de Drogas como hábil a gerar reincidência. Conforme entendimento sedimentado neste Juízo, afigura-se incongruente, assistemático, que uma fattispecie cuja condenação não gera nenhum dia de pena privativa de liberdade possa ter como efeito secundário gerar acréscimo de pena desta natureza.

O E. STF também posicionou-se no mesmo diapasão no RHC 178.512, informativo 1048 do E. STF.

Portanto, ausentes agravantes.

Descabida a minorante do § 4º do art. 33 diante dos maus antecedentes.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA apena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter hediondo da conduta. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes, tendo experimentado condenação no regime semiaberto- pgs. 150 - e não se ressocializou. Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao perfil do réu.

O réu não poderá apelar em liberdade, pois encerrada a instrução convolaram-se os indícios de autoria em provas de autoria, o que ratifica o acerto da prisão cautelar imposta. Ratifico, no mais, os fundamentos externados nas pgs. 48/57. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se a guia de execução provisória.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogada dativa. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária, ficando a cobrança suspensa na formado § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ22. 04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

- 1 - Expeça-se guia de execução definitiva;
- 2 - Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

3 - Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

4 - Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

5 - Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelo réu.

6 - Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA